

1500012-64.2020.8.26.0510

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário  
Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas  
Magistrado: MARCELA MACHADO MARTINIANO  
Comarca: Rio Claro

Foro: Foro de Rio Claro

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/01/2022

... mínimo legal, aplicação do redutor do tráfico privilegiado, e regime inicial aberto, com substituição por pena restritiva de direito e direito de recorrer em liberdade.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

O topo do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 assim descreve o delito de tráfico: Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio Claro

Foro de Rio Claro

3ª Vara Criminal

Avenida 05, nº 535, Rio Claro-SP - cep 13500-380

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500012-64.2020.8.26.0510 - lauda  
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500012-64.2020.8.26.0510

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2003986/2020 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO, 9352631 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO, 190/20/924 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO, 2003986 - DEL.INV.GER. RIO CLARO, 190/20/924 - DEL.INV.GER. RIO CLARO, 2003986 - DEL.INV.GER. RIO CLARO, 190/20/924 - DEL.INV.GER. RIO CLARO, 2003986 - DEL.INV.GER. RIO CLARO, 190/20/924 - DEL.INV.GER. RIO CLARO, 2003986 - DEL.INV.GER. RIO CLARO, 190/20/924 - DEL.INV.GER. RIO CLARO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Jadson Mateus da Silva Nascimento

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCELA MACHADO MARTINIANO

Vistos.

O representante do Ministério Público ingressou em juízo pedindo a condenação de

jadson mateus da silva nascimento, já qualificado nos autos, como incurso no topo do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.823/03, na forma do artigo 69 do Código Penal, afirmando que, em 06 de janeiro de 2020, por volta de 21h23, na Avenida 02, n. 702, bairro Jardim Novo I, nesta cidade e comarca de Rio Claro, o acusado trazia consigo, para o comércio, 60 pinos com cocaína, pesando 37g, e portava arma de fogo consistente em 1 (um) revólver, calibre 32, com numeração raspada, sem marca, municiado com quatro munições (duas picotadas e duas deflagradas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a denúncia: "Segundo se apurou, JADSON trazia consigo as porções cocaína, todas para a mercancia, bem como portava na cintura o armamento, municiado com quatro cartuchos. Na data em questão, policiais militares patrulhavam pelo bairro Jardim Novo I já tencionando coibir o comércio de entorpecentes. Tinham sido informados de que um indivíduo de prenome JADSON estaria realizando a venda de drogas na Avenida 02, esquina com a Rua 12, daquele bairro, e que também portava uma arma de fogo, em desacordo com a lei. Incontinenti, os militares se dirigiram até aquela avenida e não demorou até que percebessem um indivíduo correndo e tentando ingressar na residência de numeral setecentos e dois. Imaginando que pudesse ser a pessoa indicada nas "denúncias" recebidas, os policiais foram ao seu encalço e o abordaram antes que conseguisse adentrar a casa, ocasião em que confirmaram que se tratava do indivíduo JADSON, ora denunciado, com o qual localizaram uma pochete preta. Dentro desta pochete estavam as sessenta porções de cocaína, embaladas e prontas para serem disseminadas, e o revólver calibre 32, com numeração raspada, municiado com quatro cartuchos. JADSON portava o armamento e munições, em desacordo com a lei, uma vez que estava com seu número de identificação raspado e desacompanhado de qualquer documentação que legitimasse a posse do revólver pelo denunciado. A quantidade, a forma de acondicionamento e a natureza da substância apreendida (cocaína), as "denúncias" recebidas pela Polícia Militar de que um indivíduo de prenome JADSON estaria traficando naquele ponto do bairro, além da própria reação dele ao perceber que seria abordado, evidenciam que a cocaína tinha como destino o comércio ilegal." (fls. 51/54).

A denúncia foi recebida e o processo seguiu seu trâmite natural, com apresentação de defesa prévia, audiência de instrução e julgamento e alegações finais.

O Ministério Público pediu a condenação nos termos da denúncia, com elevação da pena em razão da natureza e quantidade de porções. Requereu a aplicação da atenuante da menoridade relativa. Na terceira fase, argumentou ser inviável a aplicação do redutor, pois a posse de arma de fogo de numeração raspada evidenciaria atividade ilícita hedionda, além de haver constatação de recentes disparos no laudo. Pleiteou a somatória de penas, na forma do concurso material de crimes, e a fixação de regime inicial fechado.

A defesa, por seu turno, reiterou a defesa preliminar e pediu a absolvição.

Subsidiariamente, requereu fixação da pena no mínimo legal, aplicação do redutor do tráfico privilegiado, e regime inicial aberto, com substituição por pena restritiva de direito e direito de recorrer em liberdade.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

O topo do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 assim descreve o delito de tráfico:

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O tipo objetivo pune diversas condutas relacionadas a substâncias entorpecentes, enquanto o tipo subjetivo consiste no dolo (vontade livre e consciente) de praticar o comércio ilícito. O objeto material é a droga, o jurídico é a saúde pública.

O artigo 16 da Lei 10.826/03 assim descreve o delito de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito: Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber,

ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O tipo objetivo pune diversas condutas relacionadas à arma de fogo, acessório ou munição de uso proibido ou restrito, enquanto o tipo subjetivo consiste no dolo (vontade livre e consciente) de praticar tal conduta.

O inciso IV do §1º do artigo 16 da Lei 10.826/03 assim descreve o delito de posse ou porte de arma de fogo com numeração raspada ou adulterada: portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado.

O tipo objetivo pune diversas condutas relacionadas à arma de fogo com sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado, enquanto o tipo subjetivo consiste no dolo (vontade livre e consciente) de praticar tal conduta.

É um tipo autônomo em relação ao previsto no topo do art. 16, só havendo identidade de pena. Se a conduta envolver arma de fogo de uso proibido, a pena é de reclusão de 4 a 12 anos, nos termos do §2º.

É crime de mera conduta, consumando-se no momento da ação, independentemente de qualquer resultado.

No caso em exame, a materialidade do delito do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 está demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 15/17, pelo auto de exibição e apreensão (fls. 18/19), pelos laudos periciais (fls. 153/155) e pela prova oral colhida.

A materialidade do delito do artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei n. 10.826/03 também está comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 15/17, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 18/19, pelo laudo pericial de fls. 56/57, e pela prova oral colhida.

A autoria também é certa.

O policial militar Danilo Gabriel Tomasini Buso em juízo afirmou: que estavam em patrulhamento por Rio Claro e receberam informações que um indivíduo estaria nesse local; que era comum ele traficar e que nessa data ele estaria portando arma de fogo; que se deslocaram até o local; que visualizaram o indivíduo com as características que foram passadas; que ele tentou se evadir, mas foi abordado no portão de uma residência; que localizaram numa pochete, durante busca pessoal, eppendorfs e cocaína, e revólver calibre 32; que a arma estava com a numeração suprimida e estava municiada com dois cartuchos deflagrados e duas munições picotadas; que estava dentro da pochete na região da cintura; que ele ficou em silêncio durante toda a ocorrência; que não o conhecia anteriormente; que nessa data foi relatado que esse indivíduo que traficava estaria portando essa arma de fogo; que essa informação chegou diretamente para a equipe através de um morador do bairro que estava indignado com a presença do indivíduo portando arma de fogo; que ele empreendeu fuga por 1 quarteirão e meio, quase 2 quarteirões; que acredita que eram familiares dele que moravam naquele local.

O policial militar Carlos Alberto Gomes, em juízo, disse: que receberam denúncia de arma e tráfico de droga; que avistaram o indivíduo; que ele tentou se evadir da equipe; que alcançaram ele pela própria via; que pegaram com pochete com pinos de cocaína, revólver calibre 32 e 4 munições; que o desconhece; que ele disse que estava na casa da namorada; que não se recorda se ele estava acompanhado de mais pessoas; que as drogas foram localizadas na pochete, que estavam na dianteira.

A depoente Indiara Fernanda Gonçalves informou em juízo: que estavam no lancheiro; que estavam com 2 amigos e se afastaram; que os policiais passaram umas duas vezes; que rodearam quarteirão e pararam; que perguntaram nome do Jadson; que pegaram ele e jogaram dentro da viatura; que levaram ele direto pra Delegacia; que não apresentaram nada; que falaram “é você mesmo” e já jogaram na viatura; que na Delegacia a mãe pediu provas e ninguém permitiu; que ele fazia bicos na época; que ele sempre foi pessoa honesta e trabalhadora, desde que o conhece; que estão juntos há 4 anos; que nunca viu arma de fogo em sua casa; que não soube que ele tem arma; que não conhece os policiais; que o companheiro não conhecia os policiais.

O acusado Jadson Mateus da Silva Nascimento, em seu interrogatório, afirmou que não

usa drogas; que estava com a esposa esperando lanche; que viu a viatura passar duas vezes; que não sabia o que estava acontecendo; que breiou em cima dele; que pegaram ele, colocaram na viatura e levaram para Delegacia; que acha que o confundiram; que nunca teve problema com isso; que tudo aconteceu no Batovi, não é perto de ponto de tráfico de drogas; que nunca viu esses policiais; que não os viu abordando ninguém ali perto; que eles não mostraram poquete; que a mãe foi logo em seguida; que sempre trabalhou; que nunca teve nenhuma passagem.

Diante do conjunto probatório, a condenação se impõe.

Os depoimentos das testemunhas de acusação foram uniformes e coerentes no sentido de que o réu realmente transportava e trazia consigo a droga (peso líquido de 4,93 gramas), 60 microtubos e uma arma de fogo com numeração suprimida, circunstâncias que não permitem concluir, sem outros elementos, que o entorpecente se destinava para uso próprio, enquadrando-se a conduta, portanto, no tipo misto alternativo descrito no delito do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, especialmente nos verbos transportar e trazer consigo.

A versão do acusado e de sua companheira restou isolada nos autos, diante da apreensão em flagrante delito e do depoimento dos policiais.

Em relação à imputação do delito do artigo 16, parágrafo único, inciso IV da Lei nº 10.826/03, respeitado o posicionamento do Ministério Público, reputo ser o caso de qualificar o fato enquanto causa de aumento do artigo 40 inciso IV da Lei n. 11.343/06: "Art. 40. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se: (...) IV - o crime tiver sido praticado com violência, grave ameaça, emprego de arma de fogo, ou qualquer processo de intimidação difusa ou coletiva;", o que faço com fundamento no artigo 383 do Código de Processo Penal, anotando, a propósito, que as partes se manifestam a respeito dos fatos e não de sua qualificação jurídica.

Isso porque o Ministério Público não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o porte de arma se deu em circunstâncias diversas da prática do tráfico ilícito de entorpecentes. Não há, nesse sentido, nenhum elemento que corrobore a versão de que se trata de condutas autônomas, tendo em vista que a descrição da apreensão em flagrante revelou que tanto o entorpecente quanto a arma foram encontradas na mesma poquete, a demonstrar que o porte de arma se deu no próprio contexto de assegurar o transporte da droga. Outros elementos que autorizariam conclusão distinta não estão presentes nos autos.

Assim, à luz dos fatos narrados, promovo a desclassificação do delito do artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03 para o delito do artigo 33, caput, cumulado com o artigo 40, inciso IV, da Lei n. 11.343/06.

A aplicação do redutor do §4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 também se impõe:

"Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa."

O réu é absolutamente primário, não ostenta maus antecedentes e não possui passagens da Infância e Juventude. Destaco, a propósito, que os policiais afirmaram que não conheciam o acusado de outras ocorrências, sendo o porte de arma insuficiente para conduzir a conclusão distinta, pois tal fato, por si só, não pode preponderar diante dos elementos citados e não deixa de ser compatível com a possibilidade de que a ocorrência consista em episódio isolado. Importante ressaltar, nesse contexto, que o laudo pericial foi inconclusivo acerca da recenticidade de disparos pela arma de fogo (fls. 56/57). Por essas razões, entendo que não está comprovado que o acusado se dedica à atividade criminosa ou que integre organização criminosa.

#### DOSIMETRIA

Atendendo aos aspectos contidos no artigo 68 do Código Penal e em observância ao princípio constitucional da individualização da pena, passo à fixação e dosimetria da pena aplicável ao acusado.

Na primeira fase, analisando as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, combinado com artigo 42, da Lei de Drogas, denota-se que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie; que não possui maus antecedentes; que poucos elementos foram coletados a

respeito da sua conduta social e personalidade, não sendo possível tal valoração; que o motivo do crime é inerente ao tipo em questão; que as circunstâncias do crime não são desfavoráveis, já que considero que, para agravar a pena com base no art. 42, da Lei de Drogas, tanto a quantidade (no caso – peso líquido de 4,93 gramas), quanto a natureza das drogas (cocaína), devem ser sopesadas em conjunto, nesse sentido: “Básicas do tráfico elevadas apenas pela espécie da droga, apesar de pequena a quantidade e, a teor do art. 42 da Lei 11.343/06, necessário considerar ambos os fatores de forma cumulada” (TJSP; Apelação Criminal 0000567-24.2018.8.26.0544; Relator (a): Vico Mañas; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Cajamar - 1ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 06/11/2020; Data de Registro: 06/11/2020). As consequências não foram gravosas, sendo que as drogas foram apreendidas; e a circunstância do comportamento da vítima não comporta aplicação no presente caso.

Diante a esses aspectos, necessários e suficientes para a reprovação e prevenção do crime, estabeleço a pena base aplicável a este caso, em sua quantidade e qualidade, nos moldes a seguir: considerando a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, anoto que o acusado faz jus à atenuante da menoridade relativa. Todavia, deixo de valorá-la devido ao óbice da Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, pelas razões acima já expostas, deve-se aplicar o redutor previsto pelo artigo 33, § 4º, da Lei 11343/2006, em seu grau máximo. A pena do réu será, pois, reduzida em dois terços, atingindo o total de um ano e oito meses de reclusão, além do pagamento de 166 dias-multa.

Por fim, pelas razões também acima expostas, de rigor a aplicação da causa de aumento de 1/6 pela incidência do artigo 40, inciso IV, da Lei n. 11.343/06.

Fixo, portanto, a pena definitiva a ser aplicada ao réu em 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 193 (cento e noventa e três) dias-multa.

Regime inicial de cumprimento da pena (art. 33, CP): Considerando o quantum da pena privativa de liberdade aplicada e as condições pessoais do condenado e, ainda, tendo em vista os critérios estabelecidos pelo artigo 59, sendo que o condenado não é reincidente, com fundamento no artigo 33, parágrafo 2º, alínea “c” e parágrafo 3º, do mesmo diploma legal, fixo, para início do cumprimento da pena, o regime aberto.

Detração da pena (art. 42 do CP e art. 387, § 2º do CPP): De acordo com a atual redação do § 2º, do artigo 387, do Código de Processo Penal, “o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade”.

Da leitura do aludido dispositivo legal, infere-se que a detração, na sentença condenatória, será necessária quando, descontado da pena definitiva fixada o tempo em que o réu ficou preso ou internado provisoriamente, houver mudança no regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, com o nítido escopo de evitar a continuidade da imposição de indevido regime mais gravoso, facilitando aos sentenciados a primeira progressão de regime.

No caso dos autos, o réu permaneceu preso durante o processo por algum tempo, porém o regime inicial fixado é o aberto, razão pela qual não se aplica a detração.

Da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, do CP): O Pleno do Supremo Tribunal Federal, com fundamento, principalmente, na garantia constitucional da individualização da pena, declarou inconstitucional a vedação à substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos aos condenados pela prática do delito de tráfico de entorpecentes (HC 97256/RS, Rel. Min. Ayres Britto).

Considerando o montante de pena aplicado, que as circunstâncias judiciais são favoráveis e, ademais, que o delito não foi cometido com grave ameaça ou violência, verifica-se a possibilidade de substituir a pena privativa de liberdade pelas penas restritivas de direitos, razões pelas quais SUBSTITUO a pena privativa de liberdade aplicada pelas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à

comunidade, por se revelar a mais adequada ao caso concreto, em busca do resgate da autoestima e aptidão para o trabalho do apenado, cabendo ao Juízo da Execução, em audiência admonitória, definir a entidade que será beneficiada com a prestação social alternativa, e prestação pecuniária no valor correspondente a 01 (um) salário mínimo, a ser pago à entidade a ser definida pelo Juízo da Execução, admitindo-se o parcelamento, conforme a situação financeira do réu.

Da suspensão condicional da pena (art. 77, do CP): Resta prejudicado o sursis em razão da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Fixação do valor do dia-multa (artigo 49, §1º, do CP): Ausentes provas capazes de aferir a exata capacidade financeira do acusado, o valor do dia-multa (artigo 49 do Código Penal) deve ser fixado em 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo nacional vigente ao tempo do fato. A pena de multa deverá ser paga nos termos e nos prazos dispostos no artigo 50 do CP, sob pena de execução.

Do direito de recorrer em liberdade (artigo 387, §1º, do CPP): Ponderando a quantidade e a natureza da pena, bem como a fixação do regime inicial aberto, o réu poderá recorrer em liberdade.

#### DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão acusatória para CONDENAR o réu JADSON MATEUS DA SILVA NASCIMENTO (RG 58013958-X, filho de Maceligye Sales da Silva e Jackson Nascimento dos Santos, à pena de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 193 (cento e noventa e três) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, como incurso no art. 33, caput, §4º, cumulado com o artigo 40, inciso IV, da Lei 11.343/2006, em regime inicial aberto, ressaltando a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito de prestação de serviços à comunidade e pena pecuniária, nos termos acima estabelecidos.

Quanto ao dinheiro apreendido, DECRETO a sua perda em favor da UNIÃO, devendo o valor ser recolhido em favor do FUNAD, já que não comprovada sua origem lícita.

Arcará o condenado com o pagamento das custas do processo, nos termos da Lei Estadual nº 11.608/03, porém, nos termos e limites do art. 98, § 3º, do CPC, diante da gratuidade da justiça concedida.

Após o trânsito em julgado: a) comunique-se o IIRGD; b) comunique-se a Justiça Eleitoral (CF, art. 15, inc. III); c) expeça-se guia para a execução definitiva da pena; e d) intime-se o réu para pagamento da multa dentro de 10 (dez) dias.

Proceda-se em relação às drogas apreendidas conforme o disposto no art. 72, LD, no que ainda couber.

Atendam-se às demais disposições do Código de Normas da Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça, no que for pertinente.

Publique-se, intemem-se e cumpra-se.

Rio Claro, 10 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA